



konkreten Einzelfall stets detailliert vorzunehmen ist. Im Modell der Lohnträgerschaft ist es sodann nicht Sache des Trägerunternehmens, für die selbstständigerwerbende Person Kunden zu akquirieren oder im Sinne der Weisungsgewalt dieser vorzuschreiben, wie die Arbeit ausgeführt werden muss. Weiter liegt die Haftung diesbezüglich keinesfalls beim Trägerunternehmen.

Das eigentlich angestrebte Ergebnis, dass eine selbstständigerwerbende Person über ein Trägerunternehmen als scheinbar unselbstständigerwerbende Person mit dementsprechend sozialversicherungsrechtlichen Pflichten und Rechten gilt, kann auch nicht durch zivilrechtliche Verhältnisse und Abmachungen herbeigeführt werden. Solche Abmachungen zwischen den Parteien sind aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht nämlich nicht bindend.

Fazit

Eine Abrechnung über ein Trägerunternehmen kann keinen Statuswechsel bei der betroffenen Person bewirken. So wird das Trägerunternehmen weder zum Arbeitgeber noch die eigentlich selbstständigerwerbende Person den Status einer unselbstständig erwerbstätigen Person erreichen.

Ermitteln die Sozialversicherungen in einem solchen Fall, dass es sich um eine Scheinunselbstständigkeit handelt, wird die betroffene Person (richtigerweise) als selbstständigerwerbend behandelt. In anderen Worten: Zwar wurden Sozialversicherungsbeiträge entrichtet, jedoch lebt dadurch in der 2. Säule kein obligatorischer Versicherungsschutz auf.

Rechtlich eher umsetzbar wäre der Ansatz, in dem das Trägerunternehmen für Selbstständigerwerbende ausschliesslich als externer

Dienstleister fungiert und administrative Arbeiten übernimmt (so etwa die allgemeine Administration, die Honorareinforderung etc.), während die selbstständigerwerbende Person sich beispielsweise freiwillig nach UVG und auch freiwillig in der beruflichen Vorsorge versichert.

FUSSNOTEN

- 1 Art. 4, 44 und 45 BVG wie auch Art. 4 UVG.
- 2 Art. 114 Abs. 2 lit. c BV.
- 3 Art. 12 ff. AVG.



AUTOR

Marco Riedi ist Geschäftsführer der Bedra GmbH in Chur. Er ist Sozialversicherungsfachmann und Ausbilder mit eidg. Fachausweis, Dozent an mehreren Weiterbildungsinstitutionen sowie Lehrgangsleiter für Sozialversicherungs- und HR-Lehrgänge an der ibW Höhere Fachschule Südostschweiz in Chur.

Der Kampf um das Personaldossier

Das Personaldossier, oft als «Personalakte» bezeichnet, nimmt in der Arbeitswelt eine zentrale Rolle ein. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff, und welche Rechte und Pflichten ergeben sich für Arbeitgeber und Arbeitnehmer? In unserem Beitrag werfen wir einen Blick auf die rechtliche Landschaft, die das Sammeln und Aufbewahren von Mitarbeiterdaten regelt.

■ Von Christina Winter und Selin Cinar

Rechtliche Einführung in das Personaldossier

Der Begriff des Personaldossiers (oft auch als «Personalakte» bezeichnet) ist gesetzlich nicht definiert. Unter dem Personaldossier wird eine Sammlung von Daten verstanden, die sich auf einen bestimmten Arbeitnehmer beziehen und in der Regel mit der Entstehung, dem Verlauf oder dem Ende eines Arbeitsverhältnisses zu tun haben. Das Sammeln (Erheben und Speichern) der Daten selbst stellt bereits eine Bearbeitung im Rechtssinne dar,¹ sodass das neue Datenschutzgesetz («DSG») darauf Anwendung findet. Zugleich sind aber auch die Arbeitsrechtsbestimmungen nach Art. 319 ff. Ob-

ligationenrecht («OR») im Hinblick auf das Personaldossier zu beachten.

Bei einem Personaldossier muss es sich nicht um eine abgeschlossene physische oder abgrenzbare Akte handeln. Es besteht nicht einmal die gesetzliche Pflicht zur Führung eines Personaldossiers. Jedoch ist die Sammlung von Daten über den Arbeitnehmer für einen Arbeitgeber letztendlich unumgänglich, beispielsweise um ein Arbeitszeugnis erstellen oder den Lohn samt Sozialversicherungsbeiträgen ausrichten zu können. Daraus resultiert für den Arbeitgeber eine praktische Pflicht zur Führung eines Personaldossiers. Die vom Arbeitgeber bearbeiteten und gesammelten Daten kön-

nen jedoch einzeln an verschiedenen Orten aufbewahrt werden und müssen sich nicht in einem abgetrennten Dossier befinden. Darüber hinaus ist es gesetzlich nicht festgelegt, was in ein Personaldossier gehört. Es finden sich lediglich Hinweise darauf, welche Daten bearbeitet werden dürfen. Hierfür ist im Arbeitsrecht Art. 328b OR massgebend. Aus dieser Bestimmung gehen die beiden entscheidenden Kriterien zur Bestimmung, ob fragliche Daten überhaupt durch einen Arbeitgeber bearbeitet werden dürfen, hervor. Gemäss Art. 328b OR dürfen nur Daten bearbeitet werden, die entweder für die Eignung eines Arbeitnehmers aussagekräftig sind oder für die Durchführung des Arbeitsverhältnisses erforderlich sind. Fehlt es an beidem, so dürfen die fraglichen Daten des Arbeitnehmers nicht bearbeitet werden. Dies ist Ausfluss des arbeitnehmerrechtlichen Persönlichkeitsschutzes, und demnach hat die Achtung dessen und die Anwendung eines sensiblen Umgangs mit Arbeitnehmerdaten eine hohe Bedeutung – das gilt insbesondere bei vermehrtem Einsatz von künstlicher Intelligenz und Big Data am Arbeitsplatz.²

Zu den gewöhnlichen Inhalten eines Personaldossiers gehören insbesondere:³



- Personalien des Arbeitnehmers
- Bewerbungsunterlagen
- Arbeitsvertrag mit allen Zusätzen
- Lohndaten, Lohnauszüge, Kontoinformationen
- Protokolle von Mitarbeitergesprächen, Mitarbeiterbeurteilungen
- Verwarnungen
- Arbeitszeiterfassungen
- Dokumente zu Absenzen, Ferienbezüge, Arztzeugnisse etc.

Rechte des Arbeitnehmers gestützt auf das neue DSG

Auskunfts- und Einsichtsrecht

Im neu revidierten DSG wurde eine Generalklausel eingeführt, die den Inhalt des Auskunftsrechts im Vergleich zum vorherigen Datenschutzgesetz ausweitet. Dem Betroffenen müssen nicht mehr nur die abschliessend definierten Pflichtinformationen geliefert werden, sondern jede Information, die erforderlich ist, um die eigenen Rechte nach dem DSG geltend machen zu können.⁴ Darüber hinaus wurde das Auskunftsrecht dahin gehend erweitert, dass neu die Aufbewahrungsdauer der Daten bzw. die Kriterien zur Festlegung dieser Dauer und das Vorliegen von automatisierten Einzelentscheiden sowie die Logik, auf der die Entscheidung beruht, ebenfalls anzugeben sind.

Das Recht auf Auskunft gemäss Art. 25 DSG umfasst alle vorhandenen Personendaten über die betroffene Person, unabhängig von der Art ihrer Speicherung.⁵ Demzufolge erstreckt sich das Auskunftsrecht auch auf in internen Akten enthaltene Personendaten. Davon ausgenommen sind nur Daten, die ausschliesslich einer Person für den persönlichen Gebrauch dienen, wie zum Beispiel persönliche Notizen des Arbeitgebers zur Vorbereitung eines Mitarbeitergesprächs. Demgegenüber können E-Mail-Korrespondenzen zwischen Vorgesetzten vom Auskunftsrecht nach Art. 25 DSG erfasst sein, aber unter Umständen nach Art. 26 Abs. 2 lit. a DSG eingeschränkt werden.⁶ Des Weiteren besteht kein vollumfänglicher Anspruch auf Einsicht in alle Unterlagen einer internen Untersuchung.⁷

Es empfiehlt sich, das Auskunftsbegehren zu Beweis Zwecken schriftlich zu stellen. Jedoch ist weder eine Begründung für das Ersuchen

noch ein besonderes schützenswertes Interesse vorausgesetzt. Eine entsprechende Begründung kann jedoch unter Umständen vor dem Hintergrund der nachfolgend diskutierten Einschränkung des Auskunftsrechts geboten sein.⁸ Sollte dem Auskunftsbegehren entsprochen werden, muss die Auskunft sowohl wahr als auch vollständig sein, wobei der Verantwortliche dafür beweispflichtig ist.⁹

Eine besondere Formvorschrift, in der die Auskunft zu erfolgen hat, ergibt sich aus dem Gesetz nicht.¹⁰ Arbeitgeber stellen die Auskunft aber in der Regel schriftlich aus, z.B. mittels Kopien oder auf elektronischem Weg.¹¹ Die zu erteilende Auskunft ist kostenlos und hat innert 30 Tagen ab Eingang des Gesuchs zu erfolgen.¹²

Berichtigungs- und Vernichtungsrecht

Das Auskunftsrecht nach DSG dient der Transparenz und dem Schutz der Persönlichkeit und ist zudem ein wichtiges Mittel, um die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Grundsätze zu kontrollieren und allenfalls eine Löschung bzw. Berichtigung der Daten zu beanspruchen.¹³

Im Falle von fehlerhaften Personendaten haben Angestellte das Recht, die von ihnen als fehlerhaft bezeichneten Personendaten berichtigen zu lassen. Von der Berichtigung sind jedoch nur Informationen erfasst, die einen Tatsachenbezug aufzeigen, nicht aber reine Werturteile sind. Bei Daten, die unzulässig erhoben bzw. die nicht weiterbearbeitet werden dürfen, besteht ein Recht des Betroffenen, die Vernichtung oder Löschung dieser zu verlangen.¹⁴

So fällt beispielsweise der Bearbeitungszweck nach Art. 328b OR mit Ende des Anstellungsverhältnisses dahin, weswegen dem Arbeitnehmer ein Anspruch auf Herausgabe bzw. auf Löschung des Personaldossiers zusteht. Soweit den Arbeitgeber noch über das Anstellungsverhältnis hinausgehende gesetzliche oder vertragliche Pflichten treffen, weil zum Beispiel die Ausstellung des Arbeitszeugnisses noch aussteht oder Rechtsstreitigkeiten zwischen den Parteien drohen, so kann das Recht auf Löschung der eigenen Daten ruhen.¹⁵

Beschränkungen der Rechte der Arbeitnehmer

Im Konfliktfall oder spätestens nach einer ausgesprochenen Kündigung fordert ein Arbeitnehmer oft unverzüglichen Zugang zu seinem Personaldossier. Wie bereits erwähnt, hat er darauf einen gesetzlich garantierten Anspruch. Jedoch besteht dieses Recht nicht unbegrenzt.

Vor der Revision des Datenschutzgesetzes konnte das Auskunfts- und Einsichtsrecht in das Personaldossier von Gesetzes wegen nur dann eingeschränkt oder verweigert werden, wenn die Einschränkung entweder gesetzlich vorgeschrieben war (z.B. zum Schutz eines Berufsgeheimnisses) oder wenn die Einschränkung durch überwiegende andere Interessen gerechtfertigt werden konnte – entweder durch überwiegende Interessen eines unbeteiligten Dritten, z.B. eines anderen Arbeitnehmers, oder durch ein betroffenes Geschäftsgeheimnis. In solchen Fällen hatte der Arbeitgeber bereits vor Revision des DSG die Möglichkeit, eine Interessenabwägung vorzunehmen und das Auskunfts- und Einsichtsrecht in das Personaldossier einzuschränken. Bei dieser Möglichkeit ist jedoch Vorsicht geboten, insbesondere wenn gegen den Arbeitnehmer, der um Auskunft ersucht, schwerwiegende Vorwürfe im Raum stehen und er sich in Bezug auf diese verteidigen muss. In solchen Fällen überwiegt oft das Interesse des Auskunftersuchenden. Entscheidend sind immer die Umstände im Einzelfall.

Neben der gesetzlich kodifizierten Einschränkungsmöglichkeit des Auskunfts- und Einsichtsrechts gestützt auf das DSG hat auch die Rechtsprechung und Praxis einen weiteren Grund zur Einschränkung des datenschutzrechtlichen Einsichts- und Auskunftsrechts in das Personaldossier für Arbeitnehmer «erschaffen». Demnach kann das Recht auf Einsicht ins Personaldossier ebenfalls abgelehnt werden, wenn das entsprechende Begehren als rechtsmissbräuchlich erachtet wird. Das Bundesgericht hielt dazu fest, dass Rechtsmissbrauch des Einsichts- und Auskunftsrechts nicht geschützt werden darf. Ein solcher «*falle in Betracht, wenn das Auskunftsrecht zu datenschutzwidrigen Zwecken eingesetzt werde, etwa um sich die Kosten einer Datenbeschaffung zu sparen, die sonst*



bezahlt werden müssten. Zu denken sei auch an eine schikanöse Rechtsausübung ohne wirkliches Interesse an der Auskunft, lediglich um den Auskunftspflichtigen zu schädigen. Eine zweckwidrige Verwendung des datenschutzrechtlichen Auskunftsrechts und damit Rechtsmissbrauch – so das Bundesgericht schliesslich – wäre wohl auch anzunehmen, wenn das Auskunftsbegehren einzig zum Zweck gestellt wird, die (spätere) Gegenpartei auszuforschen und Beweise zu beschaffen, an die eine Partei sonst nicht gelangen könnte.»¹⁶ Gestützt auf diesen (nicht arbeitsrechtlichen!) Entscheid, insbesondere des letztgenannten Grunds für einen Rechtsmissbrauch (Gegenpartei auszuforschen und Beweise zu beschaffen), wurde es dem Arbeitnehmer mit einem pauschalen Verweis auf eine «Fishing Expedition» zunehmend erschwert, Einsicht oder Auskunft in den Inhalt seiner Personalakte zu erhalten. Die pauschale Unterstellung eines rechtsmissbräuchlichen Gesuchs auf Auskunft und Einsicht in das Personaldossier führt jedoch letztlich zur Aushebelung der datenschutzrechtlich gewährten Rechte des Arbeitnehmers, denn dieser ist auf einmal dazu veranlasst, sein Begehren vermehrt zu begründen und zu rechtfertigen. Dies steht im Widerspruch zur Intention des Auskunftsrechts gemäss DSG, mit welchem auch sichergestellt werden soll, dass keine unrechtmässige Datenverarbeitung stattfindet. Selbstverständlich darf Rechtsmissbrauch nicht geschützt werden, doch kann er auch nicht leichtfertig angenommen werden.

Im revidierten DSG, das am 1. September 2023 in Kraft getreten ist, wurde die erwähnte Entwicklung der Rechtspraxis aufgegriffen und daraus ein neuer Einschränkungsground für das Einsichts- und Auskunftsrecht geschaffen. Art. 26 Abs. 1 lit. c DSG hält fest,

dass ein Auskunftsersuchen verweigert, eingeschränkt oder aufgeschoben werden darf, wenn es «*offensichtlich unbegründet*» ist, da es «*einen datenschutzwidrigen Zweck verfolgt, oder offensichtlich querulatorisch ist*». Der Gesetzgeber versucht, mit dem Kriterium der «Offensichtlichkeit» den pauschalen Verweis auf rechtsmissbräuchliche Auskunftsbegehren einzuschränken. Es bleibt abzuwarten, ob und wie dies in der Praxis künftig umgesetzt werden wird.

Rechtsschutz

Wird eine Auskunft gar nicht oder zumindest nicht vollumfänglich erteilt, so hat der einschränkende Akteur die Beschränkung zu begründen.¹⁷ Dies ebnet den Weg zum Rechtsschutz.

Die zivilrechtliche Durchsetzung des Auskunftsrechts erfolgt gegenüber Privaten mittels Zivilklage entweder im vereinfachten Verfahren (bei Streitwert ≤ CHF 30 000.–) oder im ordentlichen Verfahren (Streitwert > CHF 30 000.–). Beiden Verfahren geht jedoch eine Schlichtung voraus.

In sehr eindeutigen Fällen ist zudem ein Gesuch um Rechtsschutz in klaren Fällen nach Art. 257 ZPO denkbar. Dadurch entfällt das Schlichtungsverfahren, und somit kann ein schnelleres Verfahren durchgeführt werden.¹⁸

Fazit

Um das Personaldossier wird häufig gerungen, da beide Parteien fürchten, dass dessen Inhalt gegen sie verwendet werden könnte. Der Kampf um das Personaldossier hat sich nach der Rechtsprechung und dem Vorwurf des rechtsmissbräuchlichen Auskunfts- und Einsichtsbegehrens noch verschärft. Aus diesem Grund wurden im neuen DSG der

Umfang, Inhalt und die Beschränkungen des Auskunfts- und Einsichtsrechts ergänzt und konkretisiert.

FUSSNOTEN

- 1 Art. 5 lit. d DSG.
- 2 Vgl. Pärli/Eggmann, Das Auskunftsrecht im Privatrecht, digma 2020 S. 149.
- 3 Vgl. Emmel, Arbeitsrecht: Der korrekte Umgang mit dem Personaldossier, NZZ Nr. 99 v. 29.4.2017, S. 64.
- 4 Pärli/Flück, Art. 25 DSG, in: Baeriswyl et al. (Hrsg.), SHK – Stämpfli Handkommentar, Bern 2023, N 1.
- 5 BGE 147 III 139, E. 3.4.1.
- 6 Pärli/Flück (FN 4), N 13 f.
- 7 Fritsche, Interne Untersuchungen in der Schweiz. Ein Handbuch für Unternehmen mit besonderem Fokus auf Finanzinstitute, Zürich 2021, S. 284.
- 8 Lucic, Mitarbeiterdaten: Auskunftsrecht nach Datenschutzgesetz, RR-VR 1/2023, S. 2 & 3.
- 9 Pärli/Flück (FN 4), N 25 f.
- 10 Vgl. Art. 25 DSG.
- 11 Lucic (FN 8), S. 2 & 3.
- 12 Art. 25 Abs. 6 und Abs. 7 DSG.
- 13 Pärli/Flück (FN 4), N 5; BGE 138 III 425, E. 5.3.
- 14 Meyer, Fragen und Antworten rund ums Personaldossier, in: Der Schweizer Treuhänder 5/15, S. 353.
- 15 Wasmuth-Awyßen, Die Mitarbeiterbeurteilung aus rechtlicher Sicht, in: Müller et al. (Hrsg.), RiU – Recht in privaten und öffentlichen Unternehmen, Band/Nr. 52, Zürich 2023, N 151.
- 16 BGer 4A_277/2020, E. 5.3.
- 17 Art. 26 Abs. 4 DSG.
- 18 Vgl. Rudolph, Das Recht des Arbeitnehmers auf Einsicht in sein Personaldossier, AJP 2014, S. 1677.

AUTORINNEN



Christina Winter ist Anwältin im Bereich des Arbeitsrechts. Sie war bereits in verschiedenen auf Arbeitsrecht spezialisierten Anwaltskanzleien in Zürich und Luzern, an einem arbeitsrechtlichen Lehrstuhl in St. Gallen und am Arbeitsgericht in Luzern tätig.



Selin Cinar studiert Rechtswissenschaften an der Universität Zürich. Zudem ist sie neben ihrem Studium als Assistentin in der auf Arbeitsrecht spezialisierten Anwaltskanzlei Fischer Rechtsanwälte AG in Zürich tätig.

Impressum

Verlag WEKA Business Media AG
Hermetschloostrasse 77
CH-8048 Zürich
www.weka.ch

Herausgeber Stephan Bernhard

Redaktion Carla Seffinga

Korrektorat Margit Bachfischer M.A., Bobingen

Layout/Satz Sarah Rutschmann

Publikation 10 × jährlich, Abonnement: CHF 98.– pro Jahr, Preise exkl. MWST und Versandkosten.

Als digitale Publikation erhältlich unter:
www.weka-library.ch

Bildrechte www.istockphoto.com

Bestell-Nr. 9105

Scannen und bestellen:

Dieser Newsletter ist als gedruckte und digitale Version in unserem Shop erhältlich:



Ihre Vorteile

- Tipps und Fallbeispiele aus der Praxis
- Fokusthema in jeder neuen Ausgabe

www.weka.ch/shop

© WEKA Business Media AG, Zürich 2024 – Urheber- und Verlagsrechte: Alle Rechte vorbehalten, Nachdruck sowie Wiedergaben, auch auszugsweise, sind nicht gestattet. Die Definitionen, Empfehlungen und rechtlichen Informationen sind von den Autoren und vom Verlag auf ihre Korrektheit in jeder Beziehung sorgfältig recherchiert und geprüft worden. Trotz aller Sorgfalt kann eine Garantie für die Richtigkeit der Informationen nicht übernommen werden. Eine Haftung der Autoren bzw. des Verlags ist daher ausgeschlossen. Wenn möglich verwenden wir immer geschlechtsneutrale Bezeichnungen. Aus Platzgründen oder aufgrund einer besseren Lesbarkeit verwenden wir bei Texten nur eine Schreibweise.